

1500009-65.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... ALEX trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 3 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 10,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 133 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 161,6g, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500009-65.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2000446/2022 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DE TOLEDO DA SILVA MARIA

Réu Preso

Contr. nº 2022/000026

Aos 15 de março de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu ALEX SANDRO DE TOLEDO DA SILVA MARIA (preso nosso no CDP de Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GMS PAULO FRANCO JÚNIOR e JOEL VASCONCELOS DE LIMA

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GMS Joel e Paulo) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ALEX SANDRO DE TOLEDO DA SILVA MARIA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De acordo com a denúncia (fls. 88/90), no dia 2 de janeiro de 2022, por volta das 18 horas e 13 minutos, na rua Dom Manoel, altura do nº 1066, bairro Paulista, nesta cidade e comarca, ALEX trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 3 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 10,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 133 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 161,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O processo teve trâmite regular (fls. 91, 155 e 161). A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9; laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 151/153. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Nas fases policial e judicial, os guardas municipais, cujos relatos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, confirmaram os fatos descritos na denúncia. O guarda Joel acrescentou que o local já é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Disse que o acusado foi visto mexendo no saco de lixo. Quando foi abordá-lo, o viu jogando as porções de drogas e o dinheiro. Assim que fez isso, já colocou a mão na cabeça. O denunciado admitiu a prática do tráfico. Não havia outras pessoas nas imediações. Todas as drogas recolhidas eram idênticas. No mesmo sentido, o depoimento do guarda Paulo. Na fase informativa, ALEX optou pelo silêncio. Em Juízo, negou a conduta ilícita. Disse que possuía apenas 3 porções de cocaína, para uso próprio. Tinha 50 reais em seu poder. Não estava mexendo no saco de lixo. Comprou drogas de um tal Gabriel, que correu no momento da abordagem. Alegou que foi preso porque tinha passagem. Apesar da negativa, ao termo da instrução, o fato da denúncia ficou provado nos depoimentos seguros e uniformes dos guardas civis ouvidos sob contraditório. O acervo probatório enseja a condenação do acusado, pois a contradição entre a versão do réu e a dos milicianos resolve-se em favor desta. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais (e de guardas municipais), fortes no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (Sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). No tocante à aplicação da pena, ALEX é reincidente específico (fls. 96). Incabível a figura do tráfico-privilegiado, pois o acusado é reincidente específico e possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude (recentes), inclusive já tendo cumprido medidas socioeducativas por tráfico (fls. 110 e ss.), o que também impõe o regime fechado para coactar a reiteração delitiva. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). ALEX SANDRO DE TOLEDO DA SILVA MARIA vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente a Defesa requer seja reconhecida a ilicitude de toda a prova que embasou a presente ação penal. Com

efeito, no caso em tela, houve indevida atuação dos guardas municipais, que praticaram atos para os quais não detém competência. Ora, como se sabe, a teor do art. 144, § 8º, da CF, não é tarefa da GCM o policiamento ostensivo, que foi o que aconteceu no presente caso em que durante patrulhamento os agentes municipais acabaram suspeitando da ação do réu, motivo pelo qual resolveram abordá-los, só então apurando o que realmente acontecia. Isso, aliás, foi declarado pelos guardas municipais que disseram que abordaram o acusado por conta de um comportamento suspeito. Posteriormente, é verdade, houve a localização da droga. Mas isso não torna válido o desvio de função dos agentes municipais. A situação, outrossim, não encontra amparo na primeira parte do art. 301, do CPP, que permite que qualquer do povo efetue a prisão em flagrante. O flagrante na verdade só aconteceu porque muito antes os guardas civis municipais, por conta própria, ampliaram suas atribuições, realizando policiamento ostensivo e investigando possíveis infrações penais, o que é ilegal e inconstitucional. Não há, pois, como dizer que nessa situação, qualquer do povo poderia agir. Afinal, não se vê qualquer do povo perseguindo e revistando terceiros que reputam suspeitos. Nem mesmo fazendo entrevistas. Nessa linha, não há como não considerar que a busca pessoal efetivada é verdadeiro ato investigativo, para a qual os integrantes da GCM, reitero-se, não tem atribuição. A propósito, sobre a busca pessoal, Gustavo Henrique Badaró assim ensina: “Há divergência sobre quem teria atribuição para realizar tais buscas. Não se discute sobre a possibilidade de a autoridade policial, federal ou civil, e de seus agentes realiza-las, até mesmo porque constitucionalmente lhes incumbe a atividade de polícia judiciária (CR, art. 144, § 1º, IV, e § 4º). Por sua vez, no caso de policiais militares, a matéria é controvertida. A polícia militar, embora tenha por finalidade a prevenção ao cometimento de crimes, também tem o escopo de atividade de imediata repressão aos delitos. Assim, não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e de imediata repressão a crimes que estejam ou acabaram de ser cometidos, o policial militar não possa, desde que respeitados os requisitos legais, realizar uma busca pessoal, havendo fundada suspeita de que alguém porta uma arma ou certa quantidade de droga. Por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes”. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E no mesmo sentido assim decidiu recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP”. (STJ - HC 561.329/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020). Em acréscimo, veja ainda que recentemente o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a ilegalidade de uma prisão realizada por guardas civis municipais que incorreram em desvio de função, realizando policiamento ostensivo: “Tráfico de Drogas – Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais - Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar – Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal – Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil – Prova ilícita – Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500075-

78.2020.8.26.0546; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021). Em referido julgado, o i. Desembargador Heitor Donizete de Oliveira bem explicou que “atento à estrita legalidade, há que se reconhecer que o ordenamento jurídico só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei e, assim, no caso concreto, os guardas municipais não estavam autorizados a efetuar patrulhamento ostensivo visando combater o tráfico de drogas, abordando suspeitos na rua”, que foi exatamente o que aconteceu no caso vertente, no qual os agentes municipais reconheceram que estavam em patrulhamento visando o combate do tráfico. Enfim, por tudo que foi exposto, sendo ilícita a ação que originou a apreensão do entorpecente e a consequente prisão do réu, forçoso reconhecer que as demais provas estão contaminadas por tal ilegalidade. Assim, devem ser desconsideradas, de modo que, na falta de provas válidas, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso, no entanto, superada a questão preliminar levantada, a absolvição do acusado pela prática do tráfico, no mérito, é medida que se impõe. Isso porque o que o incrimina é apenas o que foi dito pelos guardas civis municipais, que não podem ser consideradas testemunhas totalmente isentas, tendo em vista que participaram diretamente da prisão do acusado. Sobre isso ainda deve ser considerada a possibilidade de terem atuado de forma contrária às suas atribuições, como já apontado. Assim, é evidente que os servidores municipais têm interesse em justificar seus atos, o que retira o valor probatório de seus testemunhos. Dessa forma, sendo precária a prova produzida, requer-se a absolvição do acusado em razão da falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, posto que, ainda que acolhida a versão dos agentes municipais, só seria possível vincular o réu a três eppendorfs de cocaína, o que é plenamente compatível com o uso. Além disso, o dinheiro apreendido é pouco expressivo e incapaz de caracterizar o tráfico de drogas, o qual também não foi demonstrado a partir de qualquer ato mais contundente do réu. Todavia, caso o entendimento de V. Exa seja pela condenação pelo crime descrito na inicial acusatória, a Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, já que não há qualquer motivo para exasperação, posto que a quantidade de droga não se mostrou excessiva. De qualquer modo, ele tem em seu favor a atenuante da menoridade relativa, a qual neutraliza a reincidência. Também é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, inobstante a condição de reincidente do réu. Isso porque essa circunstância será considerada para agravar a pena do réu na segunda etapa. Assim, sua utilização para negar a diminuição da pena acaba constituindo bis in idem, não autorizado pelo ordenamento jurídico, que rechaça a possibilidade da mesma circunstância ser utilizada por mais de uma vez para agravar a situação do agente. Além disso, o STJ já decidiu que a reincidência, por si só, não afasta o “tráfico privilegiado”: “A ínfima quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante da reincidência” (HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Dessa forma, nada impede que seja reduzida a pena do réu, ainda que não seja no patamar máximo. E com o reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se possível, por consequência, a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, requer-se seja conferido ao acusado o direito de apresentar eventual apelação em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

ALEX SANDRO DE TOLEDO DA SILVA MARIA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 2 de janeiro de 2022, por volta das 18 horas e 13 minutos, na rua Dom Manoel, altura do nº 1066, bairro Paulista, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 3 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 10,5g (cf. laudo de

constatação de fls. 15/17 e fotografia de fls. 12), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, ALEX tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 133 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 161,6g (cf. laudo de constatação de fls. 15/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra, a denúncia que guardas civis patrulhavam pelo lugar indicado, conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o acusado manipulando drogas junto a um saco de lixo que estava na calçada. O acusado notou a aproximação da viatura e tentou disfarçar sua conduta ilícita, afastando-se do local. Na sequência, ALEX acelerou seu passo e dispensou dinheiro (R\$ 59,00) e 3 eppendorfs contendo cocaína que tinha em seu poder.

Narra, ainda, que o acusado foi abordado pelos servidores públicos. As porções de droga e o dinheiro por ele dispensados foram recolhidos pelos guardas municipais, que também constataram a existência, junto ao saco de lixo já mencionado, (fls. 12) de outros 133 eppendorfs com cocaína pertencentes ao acusado e idênticos àqueles por ele dispensados.

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga revelaram sua destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 155). Defesa preliminar apresentada às fls. 158/159. Após, a denúncia foi recebida (fls. 161) e o réu foi citado às fls. 185.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, arguindo ilicitude da ação dos guardas civis e falta de provas.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilicitude na ação dos guardas civis e, conseqüentemente, nulidade da prova.

Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio

municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer as competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilegalidade.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação de flagrância de crime de tráfico de drogas e isso permitiu a ação dos guardas civis.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Neste sentido, há vários julgados:

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar – Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais – Não ocorrência – Existência de justa causa para a realização da medida – Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico – Possibilidade para averiguação – Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito – Mérito – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Fala dos agentes firmes e coerentes – Validade – Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório – Pena e regime que não comportam alteração – Preliminar rejeitada e recurso desprovido”. (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO – j. 05/10/2020) – g.n.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de “qualquer pessoa do povo” a proceder à prisão,

oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada a apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao

pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 25/08/2020) - g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

boletim de ocorrência de fls. 07/09;

auto de exibição e apreensão de fls. 11;

fotografia de fls. 12;

laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame químico toxicológico de fls.

151/153, ambos com resultado positivo para COCAÍNA, em relação às substâncias

apreendidas. A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05), o réu permaneceu silente.

Interrogado em juízo (gravação), negou o tráfico, dizendo que portava apenas 3 porções de cocaína e R\$ 50,00 em dinheiro. Alegou que comprou a droga do traficante Gabriel, o qual ficava naquele ponto e correu ao notar a aproximação da viatura. Os guardas o abordaram e um correu atrás do traficante, mas não o deteve. Na sua posse, eles encontraram apenas a droga, que era destinada a seu uso, e o dinheiro, que recebeu de sua mãe e pretendia usá-lo para pagar o traficante. Negou a posse das demais drogas indicadas na denúncia, dizendo que não viu onde os guardas as encontraram. Disse que não trabalhava na época dos fatos, que já teve passagens na Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais de tráfico de drogas e, depois que atingiu a maioridade, foi condenado pelo mesmo crime e havia saído da prisão 3 meses antes da data dos fatos.

A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o guarda civil Joel Vasconcelos de Lima declarou que estava com seu colega em patrulhamento de rotina e quando ingressaram na rua Dom Manoel, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, viram o réu na calçada mexendo num saco de lixo e notaram que, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou deixar o local disfarçadamente, passando a caminhar. Imediatamente foram atrás dele e, ao determinarem que parasse, ele dispensou no chão 3 porções de cocaína e R\$ 59,00 em notas em dinheiro. Na sequência, olharam o saco de lixo que o acusado manipulava e ali encontraram um saquinho vermelho contendo outras 133 porções de cocaína, idênticas às que ele havia jogado ao solo. Ele próprio indicou que guardava suas drogas ali e confessou que realizava o tráfico de drogas naquele ponto.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e em

audiência (gravação) pelo guarda civil Paulo Franco Junior.

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA



FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra de agente público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo 3 eppendorfs contendo cocaína e mantinha em depósito outros 133 eppendorfs contendo o mesmo entorpecente, para fins de mercancia e consumo de terceiros.

De fato, de acordo com a prova supra analisada, que afastou completamente a negativa do réu, este foi flagrado sozinho em local conhecido como ponto de tráfico e agiu de forma suspeita ao notar a presença dos guardas civis, pois estava mexendo num saco de lixo e, imediatamente, tentou sair disfarçadamente do local. Na iminência da abordagem, dispensou ao solo a droga que estava em sua posse (3 porções de cocaína), bem assim o dinheiro (R\$ 59,00).

No saco de lixo no qual ele mexia, os guardas encontraram outras 133 porções da mesma droga, embalada de forma idêntica às que ele dispensou.

Evidente, portanto, que todos os entorpecentes lhe pertenciam e eram destinados ao tráfico.

O destino mercantil restou evidenciado não só pelas circunstâncias dos fatos, mas também em razão da quantidade de drogas (136 porções de cocaína), incompatível com a situação de mero usuário, e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografia de fl. 12).

Outrossim, o réu possuía dinheiro, certamente obtido das vendas ilegais, eis que estava junto de parte das drogas e ele não comprovou sua origem lícita.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e

periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência probatória, bem assim o pedido alternativo de desclassificação.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência específica (fls. 96/97 - processo nº 1501280-17.2019.8.26.0599 da 3ª V.C. local, condenado por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 23/10/2019).

Por outro lado, o réu tem a seu favor a atenuante da menoridade relativa.

Como ambas as circunstâncias são consideradas preponderantes, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e tratando-se, inclusive, de reincidência específica, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (esses também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada), pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso o fato de o réu ter sofrido várias condenações por fato análogo ao tráfico de drogas antes de atingir a maioridade (certidões juntadas às fls. 110/150), o que reforça a tese de que, há tempo, vem se dedicando à atividade criminosa.

Registre-se, ainda, as graves consequências do delito de tráfico, o qual fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado em casos como esse.

Confiram-se julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apreensão de 200g de cocaína e um revólver calibre 32. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Incabível a absolvição ou desclassificação. Materialidade e autoria indúvidas. Réu detido na posse de chave de veículo automotor, em cujo interior foram encontradas a arma e as drogas. Ausência de justificativa plausível acerca dos fatos. Forma de acondicionamento do entorpecente aponta a traficância. Porte de arma e munições é delito de perigo abstrato. Arma periciada. Potencialidade lesiva atestada. Dosimetria bem realizada. Reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Regime fechado decorre do quantum da pena e da biografia penal do acusado, além da gravidade, consequências e hediondez do crime. Recurso

não provido". (TJSP - Apelação 0003463-89.2015.8.26.0400. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) -g.n.

Ressalte-se que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Anote-se, por fim, que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e quatorze dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objetivo para progressão de regime. Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu ALEX SANDRO DE TOLEDO DA SILVA MARIA a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, eis que estava junto de parte da droga e não foi comprovada origem lícita, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União. Conforme acima exposto, o réu é reincidente específico e ostenta várias condenações por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que indica que vem se dedicando há tempo à atividade criminosa em questão, fazendo desse seu meio de